

1500272-57.2022.8.26.0580

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Zander Barbosa Dalcin

Comarca: Maracaí

Foro: Foro de Maracaí

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. GRAVIDADE ABSTRATA.

IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Com relação ao tráfico privilegiado, não foram apontados fundamentos idôneos para deixar de reconhecer a sua aplicação ao caso dos autos. Acórdão impugnado baseado apenas em mera presunção de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Maracaí

Foro de Maracaí

Vara Única

Av. São Paulo, 440, Maracai-SP - cep 19840-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500272-57.2022.8.26.0580 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500272-57.2022.8.26.0580

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2171740/2022 - DEL.POL.MARACAI, 25753935 -

DEL.POL.MARACAI, 2171740 - DEL.POL.MARACAI

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

SAMIR ANDERSON AROCA LEON e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Zander Barbosa Dalcin

Vistos.

Samir Anderson Aroca Leon, Cristina Chino Quenta e Elena Acuña Mamani De Colorado foram denunciados como incursos nas penas do artigo 33, caput, combinado com artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº. 11.343/06, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, dolosamente e conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, traziam consigo e transportavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de entrega a terceiros, respectivamente, aproximadamente 70 (setenta) porções de maconha, com peso bruto aproximado de 35,68Kg; 1 (uma) porção de cocaína, com peso bruto aproximado de 7,97Kg; e mais 1 (uma) porção de cocaína com peso bruto aproximado de 8,03Kg, além de R\$ 995,85 em espécie; tudo, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 16/18, laudo de constatação de fls. 61/65 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 185/188.

Os denunciados foram notificados (fl. 236, 239 e 246) e apresentaram defesas preliminares (fls. 216/220, 265/272 e 275).

A denúncia foi recebida em 18/10/2022 (fls. 283/285).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogados os acusados (fls. 357/359).

Encerrada a instrução o Ministério Público, em Memoriais, requereu a condenação, nos exatos termos da denúncia (conforme manifestação gravada em mídia, juntada ao termo de audiência de fls. 357/359).

As defesas requereram a procedência da ação penal, com o reconhecimento da primariedade e bons antecedentes, pleitearam pela aplicação da pena no patamar mínimo e reduções com a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, bem como o direito de recorrer em liberdade (conforme manifestação gravada em mídia, juntada ao termo de audiência de fls. 357/359).

Relatei. Decido.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/07, auto de exibição e apreensão de fls. 16/18, laudo pericial de fls. 61/65 e 185/188. A autoria pelo conjunto probatório.

Samir Anderson Aroca Leon, réu, perante a autoridade policial (fl. 05) e em juízo, confessou os fatos.

Elena Acuña Mamani de Colorado, ré, durante inquérito policial apresentou depoimento em consonância com o depoimento prestado durante inquérito policial (fl. 07), afirmou que não conhecia Samir, que disseram que ela traria um 1kg e não 4 kg de drogas, tem um filho pequeno, é divorciada, fez isso por necessidade, não conhecia o Brasil. Falaram que pagariam U\$ 400,00 pelo transporte da droga, não sabia que era essa quantidade de droga.

Cristina Chino Quenta, ré, perante a autoridade policial (fl. 06) e durante a instrução, confessou os fatos, sendo que, em juízo, declarou que sabia que estava carregando drogas, é mãe solteira, que tem duas filhas, que ela que mantém as filhas, que não sabe como estão no momento. Ganharia U\$ 400,00 pelo transporte e que transportaria 1kg de droga. Tem duas filhas, de 08 anos e 14 anos de idade, estão com uma vizinha.

Rodolfo Lopes, policial militar, testemunha de acusação, durante a instrução, apresentou depoimento em consonância com o depoimento prestado perante a autoridade policial (fls. 02/03), afirmou que estava em patrulhamento pela rodovia SP-270, avistaram um ônibus próximo ao município de Maracá, km 471, abordaram o veículo, pediram documentação ao motorista. O motorista informou que estava vindo de Corumbá/MS em sentido São Paulo/SP e que estava com 22 passageiros estrangeiros, bolivianos e peruanos. Adentraram o salão do ônibus para fiscalização e verificaram que, nas poltronas de nº 13 e 14 encontravam-se duas mulheres com conversas desconexas. Pediram descessem do ônibus, verificaram que havia um volume na cintura de uma delas. Perguntaram se ela estava levando alguma coisa e confessaram que estavam levando drogas. Informaram que pegaram de uma pessoa desconhecida de Corumbá, que levariam até São Paulo e cada uma ganharia U\$ 400,00. Continuaram a fiscalização dentro do ônibus, não encontraram mais nada dentro do salão do ônibus. Quando abriram o bagageiro, já sentiram um odor meio forte e encontraram duas malas, com quase 70 pacotes de skank. Apuraram com o motorista que o dono da mala era um rapaz da poltrona nº 33, adentraram o salão novamente, verificaram que era um peruano, de nome Samir. Questionado, ele confessou que tinha pegado a droga em Corumbá/MS e que ia levar para São Paulo/SP e ganharia R\$ 5000,00 pelo transporte. A polícia civil realizou busca pessoal nas rés e constatou que estavam carregando

pasta base de cocaína. Perceberam que as duas mulheres estavam juntas mas era difícil entendê-las por conta do linguajar. Não perceberam se elas conversavam mas verificou que trocavam olhares. Samir estava sentado em poltrona separada das corréis.

Flávio Henrique dos Santos Moysés, policial militar, testemunha de acusação, em juízo, apresentou depoimento em consonância com o depoimento prestado perante a autoridade policial (fl. 04), declarou que fizeram abordagem de um ônibus, pela rodovia SP-270, km 471, no município de Maracáí/SP. Ao adentrarem no veículo, verificaram que, na poltrona de nº 13 encontrava-se a senhora Helena com volume avantajado na cintura e na poltrona ao lado, de nº 14, a senhora Cristina, também com volume avantajado. Questionaram as réis, que confessaram que estavam com drogas, que pegaram de uma pessoa desconhecida de Corumbá/MS, que colocou a droga junto ao corpo delas e que levariam até São Paulo, para entregar a uma pessoa desconhecida, no terminal rodoviário de São Paulo, e, cada uma, ganharia U\$ 400,00. Continuaram a fiscalização, não encontraram mais nada dentro do salão do ônibus. Quando abriram o bagageiro, já sentiram um odor forte de maconha e encontraram duas malas, cheia de drogas, ao todo, 70 pacotes de drogas. Apuraram com o motorista que o proprietário da mala era um rapaz da poltrona nº 33, o acusado de nome Samir. Questionado, ele confessou que tinha pegado a droga em Corumbá/MS, com uma pessoa desconhecida e que ia levar para São Paulo/SP, entregaria para uma pessoa desconhecida. Diante dos fatos, os corréis foram encaminhados à delegacia. As drogas das réis foram pesadas, carregavam 4kg de cocaína, cada uma. Samir carregava 33kg de skank.

O que demonstra a prática do tráfico ilícito de drogas é o dolo do agente de transferir ou repassar a droga a usuários, nos termos de qualquer um dos 18 (dezoito) verbos presentes no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Eis o que estabelece o artigo 33 da Lei de Antidrogas:

"Art. 33 - Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

Destarte, para a configuração do crime em apreço, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, o que afasta a exigência de se verificar a "traditio" para consumação do delito (TJSP, Apelação Criminal 1506353-79.2020.8.26.0228, Des. Klaus Marquelli Arroyo, j. 16/11/2020).

As provas coligidas são firmes e seguras a evidenciar a prática da conduta descrita na denúncia. A confissão dos acusados veio em consonância com o depoimento dos policiais militares, indicando que os fatos realmente ocorreram.

Por fim, de rigor o reconhecimento da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, pois os réus transportavam expressiva quantidade de droga desde a cidade de Corumbá/MS, com destino final em São Paulo/SP, tendo sido apreendidos em Maracáí/SP.

Passo à dosimetria da pena.

Quanto ao corréu Samir Anderson Aroca Leon

Observando o gizado no artigo 59 do Código Penal, bem como o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser

considerada normal. O acusado não possui antecedentes. Não há elementos, nos autos, que permitam aferir sua conduta social de forma negativa, bem como sua personalidade. Os motivos e as circunstâncias são próprios à espécie. As consequências foram normais. As drogas foram apreendidas em quantidade elevada a ensejar o aumento da pena-base. Nesse sentido, fixo a pena-base em 06 anos e 03 meses de reclusão e ao pagamento de 625 dias-multa, no mínimo legal, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, nos termos do artigo 43 da Lei de Drogas.

Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante da confissão, conforme artigo 65, III, alínea "d" do Código Penal. Nesse sentido, diminuo a reprimenda na fração de 1/6, perfazendo o total de 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 520 dias-multa, no mínimo legal, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, nos termos do artigo 43 da Lei de Drogas. Ausentes agravantes.

Na derradeira fase da dosimetria, presente a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e presente a causa de aumento do artigo 40, V, da Lei 11.343/2006 pois o intuito do réu era transportar os entorpecentes entre os Estados do Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Embora seja vultuosa a quantidade de entorpecentes apreendida, tal fato, por si só, não impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois prevalece o entendimento de que este fator não conduz à presunção de que o agente integre organizações criminosas, de modo que a dúvida deve prestigiar uma interpretação do dispositivo que seja mais favorável ao acusado. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. GRAVIDADE ABSTRATA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Com relação ao tráfico privilegiado, não foram apontados fundamentos idôneos para deixar de reconhecer a sua aplicação ao caso dos autos. Acórdão impugnado baseado apenas em mera presunção de dedicação ao tráfico, não apontando elemento concreto para comprovar a habitualidade ou a dedicação a atividades criminosas. 2. A jurisprudência desta Corte está consolidada na linha de que a quantidade de drogas, por si só, não constitui fundamentação suficiente para afastar a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 691.243/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Nesse sentido, em conformidade com o entendimento jurisprudencial que prevalece, será aplicado inicialmente o aumento e depois a diminuição sobre a pena já aumentada, por se tratar de procedimento mais benéfico ao acusado, eis que ambas são previstas em frações. Aplico o aumento de 1/6 à pena do tráfico, resultando num total de 6 anos e 27 dias de reclusão, e ao pagamento de 606 dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, nos termos do artigo 43 da Lei de Drogas. Em seguida, aplico a redução de 1/6, fração esta aplicada em razão da grande quantidade de droga apreendida, totalizando uma pena de 05 anos e 22 dias de reclusão, e ao pagamento de 505 dias-multa fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, nos termos do artigo 43 da Lei de Drogas, a qual torno definitiva.

Quanto à corré Cristina Chino Quenta

Observando o gizado no artigo 59 do Código Penal, bem como o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta da ré, deve ser considerada normal. A acusada não possui antecedentes. Não há elementos, nos autos, que permitam aferir sua conduta social de forma negativa, bem como sua personalidade. Os motivos e as circunstâncias são próprios à espécie. As consequências foram normais. As drogas foram apreendidas em quantidade elevada a

ensejar o aumento da pena-base. Nesse sentido, fixo a pena-base em 06 anos e 03 meses de reclusão e ao pagamento de 625 dias-multa, no mínimo legal, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, nos termos do artigo 43 da Lei de Drogas.

Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante da confissão, conforme artigo 65, III, alínea "d" do Código Penal. Nesse sentido, diminuo a reprimenda na fração de 1/6, perfazendo o total de 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 520 dias-multa, no mínimo legal, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, nos termos do artigo 43 da Lei de Drogas. Ausentes agravantes.

Na derradeira fase da dosimetria, presente a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e presente a causa de aumento do artigo 40, V, da Lei 11.343/2006 pois o intuito da ré era transportar os entorpecentes entre os Estados do Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Embora seja vultuosa a quantidade de entorpecentes apreendida, tal fato, por si só, não impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois prevalece o entendimento de que este fator não conduz à presunção de que o agente integre organizações criminosas, de modo que a dúvida deve prestigiar uma interpretação do dispositivo que seja mais favorável à acusada. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. GRAVIDADE ABSTRATA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Com relação ao tráfico privilegiado, não foram apontados fundamentos idôneos para deixar de reconhecer a sua aplicação ao caso dos autos. Acórdão impugnado baseado apenas em mera presunção de dedicação ao tráfico, não apontando elemento concreto para comprovar a habitualidade ou a dedicação a atividades criminosas. 2. A jurisprudência desta Corte está consolidada na linha de que a quantidade de drogas, por si só, não constitui fundamentação suficiente para afastar a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 691.243/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Em conformidade com o entendimento jurisprudencial que prevalece, será aplicado inicialmente o aumento e depois a diminuição sobre a pena já aumentada, por se tratar de procedimento mais benéfico ao acusado, eis que ambas são previstas em frações. Aplico o aumento de 1/6 à pena do tráfico, resultando num total de 6 anos e 27 dias de reclusão, e ao pagamento de 606 dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, nos termos do artigo 43 da Lei de Drogas. Em seguida, aplico a redução de 1/6, fração esta aplicada em razão da grande quantidade de droga apreendida, totalizando uma pena de 05 anos e 22 dias de reclusão, e ao pagamento de 505 dias-multa fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, nos termos do artigo 43 da Lei de Drogas, a qual torno definitiva.

Quanto à corré Elena Acuña Mamani De Colorado

Observando o gizado no artigo 59 do Código Penal, bem como o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta da ré, deve ser considerada normal. A acusada não possui antecedentes. Não há elementos, nos autos, que permitam aferir sua conduta social de forma negativa, bem como sua personalidade. Os motivos e as circunstâncias são próprios à espécie. As consequências foram normais. As drogas foram apreendidas em quantidade elevada a ensejar o aumento da pena-base. Nesse sentido, fixo a pena-base em 06 anos e 03 meses de reclusão e ao pagamento de 625 dias-multa, no mínimo legal, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, nos termos do artigo 43 da Lei

de Drogas.

Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante da confissão, conforme artigo 65, III, alínea "d" do Código Penal. Nesse sentido, diminuo a reprimenda na fração de 1/6, perfazendo o total de 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 520 dias-multa, no mínimo legal, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, nos termos do artigo 43 da Lei de Drogas. Ausentes agravantes.

Na derradeira fase da dosimetria, presente a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e presente a causa de aumento do artigo 40, V, da Lei 11.343/2006 pois o intuito da ré era transportar os entorpecentes entre os Estados do Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Embora seja vultuosa a quantidade de entorpecentes apreendida, tal fato, por si só, não impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois prevalece o entendimento de que este fator não conduz à presunção de que o agente integre organizações criminosas, de modo que a dúvida deve prestigiar uma interpretação do dispositivo que seja mais favorável à acusada. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. GRAVIDADE ABSTRATA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Com relação ao tráfico privilegiado, não foram apontados fundamentos idôneos para deixar de reconhecer a sua aplicação ao caso dos autos. Acórdão impugnado baseado apenas em mera presunção de dedicação ao tráfico, não apontando elemento concreto para comprovar a habitualidade ou a dedicação a atividades criminosas. 2. A jurisprudência desta Corte está consolidada na linha de que a quantidade de drogas, por si só, não constitui fundamentação suficiente para afastar a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 691.243/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Nesse sentido, em conformidade com o entendimento jurisprudencial que prevalece, será aplicado inicialmente o aumento e depois a diminuição sobre a pena já aumentada, por se tratar de procedimento mais benéfico ao acusado, eis que ambas são previstas em frações. Aplico o aumento de 1/6 à pena do tráfico, resultando num total de 6 anos e 27 dias de reclusão, e ao pagamento de 606 dias-multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, nos termos do artigo 43 da Lei de Drogas. Em seguida, aplico a redução de 1/6, fração esta aplicada em razão da grande quantidade de droga apreendida, totalizando uma pena de 05 anos e 22 dias de reclusão, e ao pagamento de 505 dias-multa fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, nos termos do artigo 43 da Lei de Drogas, a qual torno definitiva.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório para:

(i) CONDENAR Samir Anderson Aroca Leon como incurso nas sanções do artigo 33, caput, combinado com artigos 33 §4º e 40, inciso V, ambos da Lei nº. 11.343/06 à pena de 05 anos e 22 dias de reclusão, e ao pagamento de 505 dias-multa fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, nos termos do artigo 43 da Lei de Drogas;

(ii) CONDENAR Cristina Chino Quenta como incurso nas sanções do artigo 33, caput, combinado com artigos 33 §4º e 40, inciso V, ambos da Lei nº. 11.343/06, à pena de 05 anos e 22 dias de reclusão, e ao pagamento de 505 dias-multa ixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, nos termos do artigo 43 da Lei de Drogas;

(iii) CONDENAR Elena Acuña Mamani de Colorado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, combinado com artigos 33 §4º e 40, inciso V, ambos da Lei nº. 11.343/06, à pena de 05 anos e 22 dias de reclusão, e ao pagamento de 505 dias-multa fixados em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, nos termos do artigo 43 da Lei de Drogas;

Os réus deverão cumprir a pena privativa de liberdade inicialmente em regime fechado, em razão da grande quantidade de droga apreendida (cf. artigo 59 do Código Penal, bem como o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, c.c.artigo 33, § 3º,, do Código Penal).

Verifico que na situação em debate não se revela cabível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pois, embora os corréus sejam primários, a pena supera 04 anos. Outrossim, o caso concreto revela que a medida não é suficiente às finalidades preventiva e repressiva da pena (art. 44, III do CP). Além de se tratar de tráfico interestadual, foi apreendida uma grande quantidade de entorpecente com os acusados, o que permite concluir que a substância poderia ser distribuída por diversas cidades deste Estado, circunstância que supera as elementares ínsitas ao próprio tipo penal, denotando uma maior reprovabilidade da conduta no caso concreto e afastando, com isso, a possibilidade de se conceder o aludido benefício. Pelas mesmas razões, verifico que não se revela cabível a suspensão condicional de pena, nos termos do art. 77, II do CP.

Devem permanecer suas custódias cautelares, pois não modificadas as situações que demandaram sua necessidade (CPP, art. 387, § 1.º). Trata-se de crime de exacerbada gravidade (tráfico interestadual de entorpecentes), que fomenta a criminalidade e discórdia familiar nas grandes e pequenas cidades e coloca em constante desassossego a sociedade e a segurança dos cidadãos de bem. Dessa forma, a decretação da custódia cautelar permanece necessária como medida que se impõe para assegurar a ordem pública.

Ademais, no aspecto, como bem asseverado pelo Ministro Jorge Mussi, no julgamento do Habeas Corpus 68.455/DF não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva, como ocorre in casu.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. ROUBO MAJORADO TENTADO. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 3. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]

2. No caso, constatado que o paciente respondeu preso a todo o processo, a exigência de fundamentação exaustiva e a possibilidade do recurso em liberdade devem ser avaliadas com excepcional prudência. Ora, se os elementos apontados no decreto construtivo foram suficientes para manter a medida excepcional em momento processual em que existia somente juízo de cognição provisória e sumária acerca da responsabilidade criminal do acusado, com a prolação do édito condenatório precedido de amplo contraditório, no qual as provas foram analisadas por órgão judiciário imparcial, é de todo incoerente reconhecer ao condenado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado do processo quando inalterados os motivos ensejadores da medida. Noutras palavras, é incompatível com a realidade processual manter o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, preservado o quadro fático-processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-

lhe a liberdade; afinal, assim como já assinalou o Supremo Tribunal Federal, trata-se de situação em que enfraquecida está a presunção de não culpabilidade, pois já emitido juízo de certeza acerca dos fatos, materialidade, autoria e culpabilidade, ainda que não definitivo.

3. Constatado que o pedido de alteração do regime prisional não foi analisado pelo Tribunal a quo no julgamento do writ originário, fica esta Corte impedida de examinar a questão, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância. Ademais, o tema deve ser apreciado no recurso de apelação já interposto.

4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 279.487/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 14/05/2014)

Rememore-se o teor do enunciado da súmula 716 do STF: "Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória".

Carreio aos acusados o pagamento das custas, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, cuja exigibilidade, entretanto, resta suspensa por conta de litigar sob o pálio da Justiça Gratuita (CPC, art. 98, § 3º) que ora concedo. Expeça-se certidão de honorários em favor dos defensores dativos, no valor máximo da tabela oriunda do convênio entre OAB/DPE.

Transitada em julgado, determino as seguintes providências:

1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome do condenado no rol de culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 4) Extraia-se a guia de execução definitiva conforme art. 105 da Lei de Execução Penal.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

Maracá, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA